

1500496-64.2022.8.26.0266

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL VIEIRA PATARA

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Repte(a)(s):

Justiça Pública

Reqdo(a)(s):

ALEX BARBOSA DA SILVA, DOUGLAS WILLIAN CAVALHERI ARAUJO e EDMUNDO PEREIRA DE SOUSA

MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA.

Vistos.

DOUGLAS WILLIAN CAVALHERI ARAÚJO, ALEX BARBOSA DA SILVA e EDMUNDO PEREIRA DE SOUSA foram denunciados e estão sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

3ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, ., Centro - CEP 11740-000, Fone: (13) 3422-1215,
Itanhaém-SP - E-mail: itanhaem3@tjsp.jus.br

Processo nº:

1500496-64.2022.8.26.0266

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Repte(a)(s):

Justiça Pública

Reqdo(a)(s):

ALEX BARBOSA DA SILVA, DOUGLAS WILLIAN CAVALHERI ARAUJO e EDMUNDO PEREIRA DE SOUSA

MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA.

Vistos.

DOUGLAS WILLIAN CAVALHERI ARAÚJO, ALEX BARBOSA DA SILVA e EDMUNDO PEREIRA DE SOUSA foram denunciados e estão sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, porque no dia 09.03.2022, por volta das 14h00min, na Rua Boa Vista, nº 35, Balneário Tupy/Jardim São Fernando, nesta cidade e comarca de Itanhaém, os agentes supra apontados, previamente ajustados e com identidade de propósitos, tinham em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 852 (oitocentos e cinquenta e dois) "papelotes" de cocaína, 448 (quatrocentos e quarenta e oito) microtubos com cocaína, 603 (seiscentas e três) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida por maconha e 623 (seiscentas e vinte e três) pedras de crack, derivado da cocaína, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 16.03.2022 (pág. 156).

Os réus foram citados (págs. 177, 179 e 181) e apresentaram resposta escrita à acusação (págs.188/189 e 198/200).

Durante a instrução criminal foram inquiridas duas testemunhas arrolada pela acusação seguindo-se o interrogatório dos réus. (págs. 245\247).

O laudo de exame químico-toxicológico foi juntado aos autos as págs. 174/176.

Em fase de memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, condenando-os nos exatos termos da denúncia.

A defesa dos corréus Alex e Edmundo, por sua vez, requereram o reconhecimento da ilicitude da prova, determinando-se o desentranhamento e a inutilização da prova e os acusados absolvidos e caso esse não seja o entendimento, que sejam absolvidos nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, que as penas sejam fixadas no mínimo, a aplicação do redutor, fixação do regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e que possam apelar em liberdade. Por fim, a restituição dos valores apreendidos em posse da testemunha Sabrina no valor de R\$ 905,00 (novecentos e cinco reais).

A defesa de Douglas, no entanto, requereu a aplicação das atenuantes de menoridade, confissão espontânea e o redutor do parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, fixando no mínimo legal, convertendo-a em restritiva de direitos e/ao a fixação do regime inicial aberto.

É o relatório.
Fundamento e decido.

No que tange a preliminar para reconhecer a ilicitude da prova, formulada pela Defesa, razão não assiste, pois o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade de guarda é do tipo permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, como consequência, é permitida a realização da prisão em flagrante no interior da residência onde está o entorpecente, independentemente de mandado judicial.

A esse respeito, os seguintes precedentes:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO QUANDO CONFIGURADA A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE, NATUREZA DELETÉRIA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA. SÚMULA N. 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade 'guardar' é do tipo permanente, cuja consumação se protraí no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial. No caso, os policiais militares perceberam o paciente em movimentação típica de tráfico e resolveram abordá-lo, ocasião em que o acusado entrou em luta corporal com um dos milicianos a fim de desarmá-lo e se evadiu do

local, deixando cair um estojo contendo diversos entorpecentes. Ato contínuo, diante da informação de que o paciente teria se ocultado em determinada residência, se dirigiram ao local e lá adentraram, realizando a prisão em flagrante do ora paciente, bem como apreensão de diversas drogas. Nesse contexto, é Documento: 85275623 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 01/08/2018 Página 3de 5 Superior Tribunal de Justiça certa a situação de flagrante, não havendo falar nulidade por ausência de mandado de busca e apreensão. [...] Habeas corpus não conhecido" (HC 431.828/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 09/05/2018 - grifei).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). [...] 3. Quanto ao ingresso forçado dos policiais na residência do paciente, destaca-se a realização de diligências prévias a indicar seu envolvimento com o tráfico de drogas. Os agentes avistaram pessoa consumindo entorpecente em frente a uma casa conhecida como ponto de venda de drogas e, a partir da abordagem desse indivíduo - com quem foi encontrada porção de substância semelhante a maconha -, ingressaram no domicílio do acusado, onde foram apreendidas porções de cocaína e crack, além de valores em pecúnia. [...] 5. Ordem denegada" (HC 434.688/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018 - grifei).

Posto isso, REJEITO a preliminar.

Ao mérito, pois.

A ação é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 04/05), pelo boletim de ocorrência (págs. 12/16), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 17/19), pelo auto de constatação preliminar (págs. 20/21), pelo laudo de exame químico toxicológico (págs. 173/176), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é inconteste e deve ser atribuída aos acusados.

A testemunha arrolada pela acusação, Carlos Henrique Estefane da Hora, ouvido em Juízo, Policial Civil, disse que foram informados através de uma denúncia anônima de que um rapaz de vulgo "DG" gerenciava um ponto de drogas no bairro Sabaúna. Informou que já haviam elaborado pedido de busca e apreensão, mas que na data dos fatos, após denúncia anônima, se deslocaram ao local e puderam avistar o veículo "Renault Megane" estacionar defronte ao nº 35, oportunidade em que três homens, uma mulher e uma criança saíram do automóvel e adentraram ao imóvel. Asseverou que efetuaram a aproximação a pé e, através de uma janela que dá acesso ao interior do imóvel, ouviram conversa referente à quantidade de drogas e puderam observar os réus com os entorpecentes e, diante do estado de flagrância, decidiram por abordá-los, sendo que avistaram os três acusados fazendo a contagem dos entorpecentes.

A testemunha arrolada pela acusação, Luciano ouvido em Juízo, Policial Civil, apresentou os mesmos fatos que seu colega de profissão, informando que Douglas confessou informalmente a traficância.

Não há razão suficiente para invalidar os depoimentos dos Policiais, por suspeitos

ou impedidos de depor, só porque ostentam essa qualidade, pois, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que:

"(...) nada impede que policiais ou outros servidores públicos, como quaisquer pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos destes como se, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos de seus próprios servidores. A propósito do valor probante de testemunhos policiais, oportuno trazer à colação a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal: 'VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.'" (HC 73518, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293)" (TJSP, Apelação nº 0009710-21.2011.8.26.0176, 14ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER, j. 31.03.2016).

Os testemunhos dos Policiais são suficientes para, com as demais provas carreadas aos autos, comprovarem a ocorrência do fato típico, e embasarem um decreto condenatório aos réus, vez que dotados de fé pública e idoneidade em suas alegações, mormente por terem corroborado os depoimentos na fase inquisitorial.

O réu, Douglas Willian Cavalheri Araújo, interrogado em Juízo, confessou os fatos descrito na denúncia. Disse que era responsável por guardar e distribuir os entorpecentes e, para tal, recebia em média R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pelo serviço. Informou que conhecia o Edmundo e o chamou para realizar a venda dos entorpecentes, tendo este convidado Alex, e os dois receberiam R\$ 30,00 (trinta reais) a cada R\$ 140,00 (cento e quarenta reais) de drogas vendidas.

O réu, Alex Barbosada Silva, interrogado em Juízo, confessou os fatos descritos na denúncia. Disse que estava passando por necessidade financeira, motivo pelo qual aceitou a proposta de vender os entorpecentes.

O réu, Edmundo Pereira De Sousa, interrogado em Juízo, confessou os fatos descritos na denúncia. Disse que diante da necessidade financeira que estava passando aceitou a proposta do Douglas, bem como convidou Alex para atuar na prática ilícita.

Pois bem.

A responsabilidade penal dos réus é nítida, mormente pelas provas colhidas, em especial pela prisão em flagrante e o auto de exibição e apreensão, somados aos depoimentos e as confissões espontâneas dos réus, tornando-se prova idônea da prática delitiva.

Necessário destacar, ainda, que o tráfico de drogas é praticado às ocultas, logo, para se prolatar decisão condenatória não há necessidade de uma sequência de provas plenas e fartas, pois tal situação não se coaduna com a realidade fática.

A decisão condenatória deve se basear em um quadro suficiente de elementos de

convicção, que seja harmônico e convergente para configurar a conduta dos réus, o que de fato ocorre no presente caso.

Ainda que assim não fosse, é sabido que todos os processos criminais exibem, em maior ou menor escala, algum coeficiente de incerteza, cumprindo ressaltar, porém, que é despropositado exigir, para a procedência da acusação, grau absoluto de certeza, de vez que a solução condenatória reclama, tão só, prova suficiente da autoria e da materialidade, que não se identifica com prova maciça, incontestável, reflexo sem distorções da realidade. E prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível, ou seja, juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão.

Nem se diga que a existência apenas de indícios impossibilite um decreto condenatório, pois contrariaria doutrina e jurisprudência majoritárias:

"embora não leve à certeza, a jurisprudência tem admitido a condenação quando a prova indiciária for veemente ou então quando várias pequenas circunstâncias sejam, concordes até em detalhes. Um único indício pode levar à condenação, desde que veemente. Por indício veemente entende-se aquele que, dada a sua natureza, permite razoavelmente afastar todas as hipóteses favoráveis ao acusado. (...) Às vezes uma sucessão de pequenos indícios, coerentes e concatenados, igualmente podem dar a certeza exigida para a condenação. (...) Em tal hipótese não encontramos um indício que possa ser classificado como veemente, porém a sucessão e a coerência indicam a autoria com uma dose de razoabilidade bem marcante" (Da Prova no Processo Penal - José Q. T. de Camargo Aranha).

"A prova se faz não só de maneira direta, mas também por indícios e presunções, que devem ser analisados como todo e qualquer outro elemento de convicção, à luz do princípio do livre convencimento do Juiz. Os indícios, quando não contrariados por contra indícios, ou por prova direta, autorizam o juízo e culpa do acusado e sua condenação." (TACRIM-SP - AC - Rel. Marrey Neto - JTACRIM 7/105).

Contudo, como se vê, ficou clara a prática de tráfico ilícito de entorpecentes por parte dos réus, inexistindo nos autos qualquer fato que venha ilidir a responsabilidade penal.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade e diversidade, denotam, às claras, sua predisposição: a entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, Acr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Para ilustrar, aponto as lições de LUIZ FLÁVIO GOMES:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Devem-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa,

as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. Al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Nesta toada, o conjunto probatório delineado nos autos é mais do que suficiente para empregar o decreto condenatório em desfavor dos réus.

Passo a dosar a pena.

RÉU DOUGLAS WILLIAN CAVALHERI ARAÚJO

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, e analisando a folha de antecedentes (pág. 88) observo que o réu não possui maus antecedentes, todavia, analisando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas, que é preponderante sobre o artigo 59 do Código Penal, verifico que a quantidade e natureza das drogas apreendidas, constituem fundamento apto a ensejar o aumento da pena-base, neste sentido, tem decidido o E. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. PREPONDERÂNCIA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. NATUREZA NOCIVA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉ PRIMÁRIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. QUANTIDADE DA DROGA NÃO EXPRESSIVA. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. [...]" (HC 366112 / SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016; grifei).

Desta forma, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante de confissão espontânea, todavia, não há que se diminuir a pena aquém do mínimo legal, por força da súmula 231 do STJ, desse modo, retorno a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

À míngua de outras circunstâncias, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ademais, anote-se que a quantidade de drogas apreendidas também impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Segundo o renomado jurista e magistrado Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol.1 -Ed. Forense - 8ª ed. - 2014 -

página 348" – a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 "cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda."

Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse.

Todavia, a grande quantidade de droga envolvida também é indicativo de que o acusado efetivamente se dedicava a atividade criminosa, integrando organização criminosa, posto que é insustentável que um traficante iniciante tenha condições financeiras (lucro próprio do tráfico), para adquirir, fracionar e embalar sozinho, a quantidade de entorpecente dos autos, concluindo-se que, ou recebeu as drogas de pessoa hierarquicamente superior na organização criminosa, ou a muito tempo vem comercializando as drogas, a ponto de ter dinheiro o suficiente para adquirir a grande quantidade apreendida. Tornando prova apta a indicar que este seria o seu meio de sustento, caracterizando sua dedicação à atividade criminosa.

Desta forma, impossível à concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no caso em tela.

Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força de expressa proibição legal, e por ser a pena superior a 04 anos. Assim como, em relação à concessão do "sursis" processual.

Dito isso, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, único adequado e suficiente para reprovar sua conduta que afeta significativamente a ordem social, tendo em vista o incurso no artigo 2º, §1º da Lei nº 8.072/90, com a redação pela lei 11.464/07, os quais justificam a imposição do regime inicial mais severo.

RÉU ALEX BARBOSADA SILVA

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, e analisando a folha de antecedentes (págs. 93/99) observo que o réu possui maus antecedentes, desse modo, majoro em 1/6 (um sexto) a pena provisória, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante de confissão espontânea, todavia, não há que se diminuir a pena aquém do mínimo legal, por força da súmula 231 do STJ, desse modo, retorno a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

À míngua de outras circunstâncias, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Anote-se que a presença de maus antecedentes impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Segundo o renomado jurista e magistrado Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – vol.1 –Ed. Forense – 8ª ed. – 2014 – página 348" – a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 "cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de

primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda."

Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse.

Segundo o mesmo jurista acima citado, inclusive na mesma obra, "na norma do §4º, para que se possa aplicar a diminuição de pena, afastou-se a possibilidade de ser reincidente ou ter maus antecedentes".

Desta forma, o réu tendo maus antecedentes impossível à concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no caso em tela.

Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força de expressa proibição legal, e por ser a pena superior a 04 anos. Assim como, em relação à concessão do "sursis" processual.

Dito isso, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, único adequado e suficiente para reprovar sua conduta que afeta significativamente a ordem social, tendo em vista o incurso no artigo 2º, §1º da Lei nº 8.072/90, com a redação pela lei 11.464/07, os quais justificam a imposição do regime inicial mais severo.

RÉU EDMUNDO PEREIRA DE SOUSA

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, e analisando a folha de antecedentes (pág. 91) observo que o réu não possui maus antecedentes, todavia, analisando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas, que é preponderante sobre o artigo 59 do Código Penal, verifico que a quantidade e natureza das drogas apreendidas, constituem fundamento apto a ensejar o aumento da pena-base, neste sentido, tem decidido o E. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. PREPONDERÂNCIA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. NATUREZA NOCIVA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉ PRIMÁRIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. QUANTIDADE DA DROGA NÃO EXPRESSIVA. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. [...]" (HC 366112 / SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016; grifei).

Desta forma, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-

multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante de confissão espontânea, todavia, não há que se diminuir a pena aquém do mínimo legal, por força da súmula 231 do STJ, desse modo, retorno a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

À míngua de outras circunstâncias, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ademais, anote-se que a quantidade de drogas apreendidas também impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Segundo o renomado jurista e magistrado Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol.1 -Ed. Forense - 8ª ed. - 2014 - página 348" - a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 "cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.".

Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse.

Todavia, a grande quantidade de droga envolvida também é indicativo de que o acusado efetivamente se dedicava a atividade criminosa, integrando organização criminosa, posto que é insustentável que um traficante iniciante tenha condições financeiras (lucro próprio do tráfico), para adquirir, fracionar e embalar sozinho, a quantidade de entorpecente dos autos, concluindo-se que, ou recebeu as drogas de pessoa hierarquicamente superior na organização criminosa, ou a muito tempo vem comercializando as drogas, a ponto de ter dinheiro o suficiente para adquirir a grande quantidade apreendida. Tornando prova apta a indicar que este seria o seu meio de sustento, caracterizando sua dedicação à atividade criminosa.

Desta forma, impossível à concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no caso em tela.

Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força de expressa proibição legal, e por ser a pena superior a 04 anos. Assim como, em relação à concessão do "sursis" processual.

Dito isso, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, único adequado e suficiente para reprovar sua conduta que afeta significativamente a ordem social, tendo em vista o incurso no artigo 2º, §1º da Lei nº 8.072/90, com a redação pela lei 11.464/07, os quais justificam a imposição do regime inicial mais severo.

Posto isto,

CONDENO o réu DOUGLAS WILLIAN CAVALHERI ARAÚJO qualificado nos autos, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, a iniciar o cumprimento no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal.

CONDENO o réu ALEX BARBOSADA SILVA qualificado nos autos, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, a iniciar o cumprimento no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal.

CONDENO o réu EDMUNDO PEREIRA DE SOUSA ARAÚJO qualificado nos autos, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, a iniciar o cumprimento no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal.

Recomende-se os réus na prisão em que se encontram, não podendo recorrer em liberdade, pois ainda presentes os requisitos da custódia cautelar.

Também, após o trânsito em julgado, oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens eventualmente apreendidos em poder dos réus em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Oportunamente, intime-se os réus para efetuarem o pagamento da multa.

Condeno-os, ainda, ao pagamento das custas processuais, observando-se eventual condição de beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Arbitro os honorários dos defensores nomeados, se o caso, no valor máximo da tabela vigente, expeça-se o necessário.

P.I.C- Arquivando-se, oportunamente.

Itanhaém, 30 de novembro de 2022.

RAFAEL VIEIRA PATARA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA